



Roj: **SAN 1386/2017 - ECLI:ES:AN:2017:1386**

Id Cendoj: **28079230022017100136**

Órgano: **Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **2**

Fecha: **30/03/2017**

Nº de Recurso: **224/2015**

Nº de Resolución: **165/2017**

Procedimiento: **PROCEDIMIENTO ORDINARIO**

Ponente: **JESUS MARIA CALDERON GONZALEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **TEAC, 05-03-2015,**
SAN 1386/2017

AUDIENCIA NACIONAL

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN SEGUNDA

Núm. de Recurso: 0000224 / 2015

Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General: 02747/2015

Demandante: Inocencio

Procurador: CARMEN GARCÍA MARIN

Demandado: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL

Abogado Del Estado

Ponente Ilmo. Sr.: D. JESÚS MARÍA CALDERÓN GONZALEZ

SENTENCIA Nº:

Ilmo. Sr. Presidente:

D. JESÚS MARÍA CALDERÓN GONZALEZ

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. MANUEL FERNÁNDEZ LOMANA GARCÍA

Dª. CONCEPCIÓN MÓNICA MONTERO ELENA

D. FERNANDO ROMÁN GARCÍA

Dª. TRINIDAD CABRERA LIDUEÑA

Madrid, a treinta de marzo de dos mil diecisiete.

Visto el recurso contencioso-administrativo que ante esta Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y bajo el número **224/2015**, se tramita a instancia de **Inocencio**, representado por la Procuradora doña Carmen García Martín, contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 5 de marzo de 2015, relativa a **Impuesto sobre Renta No Residentes, ejercicio 2009, denegación de devolución**; y en el que la Administración demandada ha estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, siendo la cuantía del mismo de 158.532,56 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO . - La parte indicada interpuso, en fecha, 13 de mayo de 2015, este recurso respecto de los actos antes aludidos, admitido a trámite y reclamado el expediente administrativo, se entregó éste a la parte actora para que formalizara la demanda, lo que hizo en tiempo; y en ella realizó una exposición fáctica y la alegación de los preceptos legales que estimó aplicables, concretando su petición en el suplico de la misma, en el que literalmente dijo:

"SUPlico a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que tenga por presentado este escrito, con el expediente administrativo que se devuelve; que tenga por formalizada la demanda, entregándose las preceptivas copias al Sr. Abogado del Estado en su condición de representante de la Administración demandada; y, previos los trámites oportunos, dicte en su día Sentencia estimatoria por la que se anule la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 5 de marzo de 2015, por ser contraria a Derecho y en consecuencia ordene:

I. CON CARÁCTER PRINCIPAL, procedencia de la devolución de los 158.532,56 ? resultantes de la autoliquidación del IRNR 2009 en su día presentada por mi mandante más los oportunos intereses de demora y condena en costas a la parte contraria.

II. SUBSIDIARIAMENTE que, en el caso de desestimación de la petición principal por no considerar aplicable a la indemnización percibida por el Sr. Inocencio la exención prevista en el artículo 7 LIRPF, dicte Sentencia por la cual ordene la devolución del importe de 86.532,56 ? más los correspondientes intereses de demora, resultante de la aplicación a las rentas obtenidas por el Sr. Inocencio en 2009 del tipo de gravamen fijo del 24% previsto para contribuyentes no residentes, y condena en costas a la parte contraria."

SEGUNDO .- De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado, quien en nombre de la Administración demandada contestó en un relato fáctico y una argumentación jurídica que sirvió al mismo para concretar su oposición al recurso en el suplico de la misma, en el cual solicitó:

"SUPlica A LA SALA que, teniendo por presentado este escrito, se admita y se tenga por CONTESTADA LA DEMANDA dictándose, tras los trámites legales, sentencia en la que se desestime íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el demandante con expresa condena en costas "

TERCERO .- Solicitado el recibimiento a prueba del recurso, la Sala dictó auto, de fecha 19 de noviembre de 2015, acordando el recibimiento a prueba, con el resultado obrante en autos.

Seguó el trámite de Conclusiones, a través del cual las partes, por su orden, han concretado sus posiciones y reiterado sus respectivas pretensiones, tras lo cual quedaron los autos pendientes de señalamiento, lo que se hizo constar por medio de diligencia de ordenación de 15 de enero de 2016 y finalmente, mediante providencia de 20 de febrero de 2017 se señaló para votación y fallo el 23 de marzo de 2017, fecha en la que efectivamente se deliberó y votó.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso contencioso-administrativo se han observado las prescripciones legales exigidas por la Ley reguladora de esta Jurisdicción, incluida la del plazo para dictar sentencia. Y ha sido **Ponente el Ilmo. Sr. D. JESÚS MARÍA CALDERÓN GONZALEZ, Presidente de la Sección**, quien expresa el criterio de la Sala.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo se interpone por la representación de don Inocencio , contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 5 de marzo de 2015, por la que se desestima la reclamación económico administrativa formulada, en única instancia, por el recurrente contra la Liquidación Provisional de 8 de abril de 2011, practicada por la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (la Oficina Gestora), notificada a dicho contribuyente el 31 de Mayo de 2011, denegándole la devolución solicitada por importe de 158.532,56 ?.

Son antecedentes a tener en cuenta en la presente resolución y así derivan del expediente administrativo, tal como reseña la resolución recurrida, los siguientes:

PRIMERO: Mediante escrito con fecha de entrada en la Oficina Gestora el 18 de Enero de 2010, el Sr. Inocencio (el interesado, el reclamante y el obligado tributario) solicitó la devolución de 158.532,56 euros correspondientes a una parte de la retención que le había practicado la mercantil Hugo Boss España, S.A. (hoy Hugo Boss Ibérica, S.A.) sobre sus retribuciones por trabajo del año 2009. El escrito complementaba la declaración efectuada ese mismo día por el interesado en el modelo 210 correspondiente a la autoliquidación

que presentó por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), ejercicio 2009. Las alegaciones que efectuaba en la solicitud eran, sustancialmente:

- El interesado manifestaba que desde el día 1 de Abril de 2009 trabajaba y vivía en Suiza, lo que acreditaba mediante un certificado de residencia fiscal expedido por la Administración tributaria suiza del cantón de Ticino que adjuntaba a su escrito como documento n.º 2. El documento, redactado en idioma italiano, exponía, conforme a la traducción que acompañaba que «[e]l Sr. Inocencio , NUM000 .1967, en virtud de lo establecido en el artículo 4 del convenio para evitar la doble imposición vigente entre Suiza y España así como del artículo 3 de la LIFD y del artículo 2 de la LT está ilimitadamente sujeto a tributación en Suiza, Cantón Ticino, Comunidad de Mendrisio, tal y como comunicamos en la certificación del 16.06.09 cuya copia se adjunta a la presente.» El certificado se refería como *periodo de sujeción (periodo d'assogettamento)* del interesado a la tributación en ese cantón suizo de Ticino desde el 01/04/2009 al 31/12/2009.

- Consideraba que al ser residente fiscal en Suiza en 2009, los rendimientos obtenidos de su anterior empleador, Hugo Boss España, S.A., estaban sujetos a tributación al 24%, pero dicha compañía le practicó retenciones mucho más altas, constituyendo esta circunstancia el primer motivo que originaba la cuota a devolver por la Administración tributaria.

- La compañía Hugo Boss España, S.A. despidió al interesado mediante carta de 4 de junio de 2009. Este último adjuntaba a su escrito una copia de esa carta de despido como documento n.º 3.

Como consecuencia del despido le fue satisfecha al hoy reclamante una indemnización por importe de 300.000 €, tal y como se desprende del finiquito cuya copia adjuntaba a su escrito como documento n.º 4.

- Manifestaba que, atendiendo al finiquito en cuestión, podía apreciarse que la compañía Hugo Boss España, S.A. procedió a retenerle el 43% del importe a percibir, sin tener en cuenta que el importe de la indemnización se considera exento dentro de los límites previstos en el Estatuto de los Trabajadores, según lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (LIRPF), aplicable a los no residentes en virtud de la remisión prevista en el artículo 24.1 (*rectius* 14.1) reguladora del IRNR.

El interesado procedía a continuación a cuantificar el importe de la indemnización que consideraba exenta conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Atendiendo a esa normativa la indemnización procedente ascendería –afirmaba–, a 45 días de salario por año de servicio, con el límite de 42 mensualidades. Tal y como se desprendía del finiquito aportado con su escrito de solicitud como documento n.º 4, el interesado exponía que comenzó a trabajar en Hugo Boss España, S.A. con fecha 1 de julio de 2002. Y fue despedido el día 4 de Junio de 2009. En consecuencia tenía una antigüedad en la empresa de 6,93 años (6 años completos, mas medio año en 2002 y 157 días en 2009). A su vez, durante los últimos doce meses en los que trabajó para Hugo Boss España, S.A. percibió un importe total de 417.065 euros, sin tener en cuenta el importe de la indemnización. A efectos acreditativos aportaba como documento agrupado nº 5 copias de las nóminas de los meses de julio de 2008 a junio de 2009, ambos inclusive.

El interesado afirmaba que una mensualidad ascendía a $(417.840/12=)$ 34.820 €, de lo que a su vez resultaba que el importe de la indemnización que afirmaba que le correspondería obtener según el Estatuto de los Trabajadores ascendería a $(34.820 \times 1,5 \times 6,93 =)$ 361.954 €. Añadía que estaba "en pleitos" – cuya existencia, sin embargo, no probaba ni concretaba – con su anterior empleadora con el fin de reclamar el importe total de la indemnización procedente. Consideraba que al ser inferior la indemnización obtenida, había de concluirse que el total importe de la indemnización estaba exento de tributación.

Las cantidades consignadas en la autoliquidación por el IRNR adjuntada como documento nº 1 a su escrito de solicitud de devolución, eran la suma de los rendimientos del trabajo que fueron satisfechos por Hugo Boss España en 2009, sin incluir el importe de la indemnización, multiplicado por el tipo impositivo del 24%, lo que daba lugar a una cuota íntegra por importe de 44.482,61 €. Al haber retenido la empleadora la cantidad de 203.015,17 €, tal y como se desprendía de las correspondientes nóminas (documento agrupado nº 5), afirmaba que procedía que la Administración tributaria le devolviera la diferencia, es decir, la cantidad de 158.532,56 €.

SEGUNDO: La Oficina Gestora requirió al interesado para que aportase:

- Traducción realizada por traductor oficial del documento nº 2 aportado en la solicitud.
- Contrato de trabajo con su anterior empleadora: 'HUGO BOSS ESPAÑA S.A.

El Acuse de Recibo (AR) del requerimiento figura en el expediente con fecha de 03/01/2011 y domicilio de recepción en 28224-Pozuelo de Alarcón (Madrid), CALLE000 nº NUM001 .

TERCERO: Mediante escrito presentado con fecha 14/01/2011 el interesado solo parcialmente dio cumplimiento a lo requerido aportando la traducción de la certificación de residencia en Suiza pero no el contrato de trabajo con la excusa de que se celebró de palabra, citando al efecto el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores. Reiteró como domicilio a efecto de notificaciones el antes indicado y solicitó la devolución del importe solicitado y los intereses de demora correspondientes.

CUARTO: Con fecha de 08/04/2011, la Oficina Gestora adoptó acuerdo por el que practicó liquidación provisional de la que se derivaba que no existía cantidad alguna a devolver lo que así declaraba.

Dicho acuerdo se notificó al interesado con fecha 31/05/2011. La Liquidación Provisional practicada por la Oficina Gestora tiene la siguiente motivación:

«El artículo 105.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria dispone que en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo. Referido a la residencia fiscal el artículo 9.1 del TRLIRPF establece que se considera que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando concurren cualquiera de las siguientes circunstancias: que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español o que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o de sus intereses económicos, de forma directa o indirecta. La no aportación de prueba suficiente por parte del contribuyente provoca la aplicación del criterio de permanencia si no acredita la residencia en otro país, y el de interés económico si no prueba la concurrencia de más intereses en otra jurisdicción.

- El contribuyente fue residente fiscal en España desde su traslado el 14 de marzo de 2002, presentado declaración del I.R.P.F. desde el año 2003 hasta el 2008. Durante el 2009 estuvo en España y obtuvo rentas por trabajo desarrollado en España hasta la fecha de la extinción de su contrato de trabajo por despido (Carta de despido aportada de fecha 4 de junio de 2009); (Nómina y finiquito de 1 de junio a 30 de junio del citado año); aunque el contribuyente manifiesta que desde el 1 de abril vivía y trabajaba en Suiza.

- La entidad "Hugo Boss España SA" para la que Vd. estuvo trabajando le considera residente fiscal en España, ya que le incluyó en el resumen anual modelo 190 en el que se declaran a la personas que han obtenido Rendimientos a cuenta del IRPF.

- Su cónyuge e hijo fueron residentes fiscales en España durante el 2009 como lo demuestra la declaración del IRPF presentada por la misma.

- En cuanto a los documentos aportados: certificado de sujeto fiscal en Suiza expedido el 16 de junio de 2009 y el fechado el 21 de septiembre de 2009 en el que "INTERFIDA SA" solicita la confirmación de los datos en el expresados referidos al contribuyente; ésta Oficina considera que no justifica la residencia fiscal en Suiza durante el citado ejercicio 2009.

- No obstante lo anterior hay que señalar que, el importe por rendimientos de trabajo obtenidos en España por el contribuyente asciende a 485.344,22 euros; Dicho importe debe constituir la Base Imponible puesto que no es de aplicación la exención del art.7 e) de la Ley de IRPF, art.14.1 a) del R.O. Legislativo 5/2004 del IRNR a la indemnización por despido: 300.000,00 euros. En éste sentido también lo interpretó la empresa "Hugo Boss España SA" cuando le practicó la retención y abonó el finiquito.

- El tratamiento fiscal derivado de las indemnizaciones por despido vienen determinadas por la naturaleza de la relación laboral mantenida, esto es, si es común o especial. Aunque a requerimiento de la Administración el contribuyente alega que el contrato de trabajo fue verbal, según el documento en el que la empresa le notifica la extinción del contrato de trabajo por despido señala que su puesto es de Director General de "Hugo Boss España SA" y en otro párrafo "de conformidad con la legislación laboral que regula su relación laboral de alto directivo".

- En los supuestos de cese de la relación laboral especial que une a una empresa con el alto directivo, caso del contribuyente, regulada por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto (BOE de 12 de Agosto) la Dirección General de Tributos entiende que al no existir ningún límite máximo fijado con carácter obligatorio por el citado Real Decreto la totalidad de la indemnización satisfecha está plenamente sometida al impuesto y a sus sistema de retenciones a cuenta (DGT 2185-00,V0325-05,0745-02).

- El artículo 9.1 del citado TRLIRPF establece que: "Para determinar el período de permanencia en territorio español de un sujeto pasivo se computarán sus ausencias temporales, salvo que demuestre su residencia habitual en otro país durante 183 días en el año natural".

- Como puede observarse, a la hora de computar la permanencia por más de 183 días, habrá de sumarse al tiempo de permanencia las ausencias temporales, salvo que se demuestre que se ha sido residente fiscalmente en otro país; y como se ha expresado anteriormente no queda demostrada la residencia fiscal del contribuyente en otro país (Suiza) puesto que no se considera que la documentación aportada lo acredite.»

QUINTO: El interesado, disconforme con el acuerdo de la Oficina Gestora, interpuso ante este Tribunal reclamación económico administrativa en única instancia a la que se asignó el R.G. NUM002 . Se le dio trámite para alegaciones y aportación y proposición de pruebas, notificado en el domicilio que designó a efecto de notificaciones de 28224-Pozuelo de Alarcón (Madrid), CALLE000 n° NUM001 (el AR del mencionado trámite es de fecha 17/09/2012).

En el escrito mediante el que evacuaba ese trámite procesal, el reclamante hizo figurar el número de salida del Registro General del TEAC que figuraba en el oficio de la Abogada del Estado-Secretaria de este Tribunal (NUM003) por el que se le confería el mencionado trámite y no el número de la reclamación de que se trataba (NUM002). Esa circunstancia provocó un error en este Tribunal que le llevó a entender que el interesado no había hecho uso del trámite indicado y dictó Resolución de fecha 28/02/2013 sin tener en cuenta las alegaciones y prueba formuladas por el interesado (cfr. su Fundamento de Derecho [FD] Segundo). El fallo desestimó la reclamación y la resolución fue notificada al interesado el 07/03/2013.

SEXTO: El reclamante interpuso recurso de anulación ante este Tribunal contra la Resolución de 28/02/2013 al amparo del artículo 239.6.b) de la LGT que prevé como uno de los casos para el que dicho recurso se establece que *"se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas oportunamente presentadas."* Al recurso de anulación le fue asignado el R.G. 3133/11/50-A.

Practicadas las pertinentes averiguaciones se comprobó la existencia del error padecido y mediante Resolución de este Tribunal de 02/06/2014 (R.G. 3133/11/50-A) se estimó el recurso de anulación interpuesto por el interesado y se anuló la Resolución de fecha 28/02/2013 que había desestimado la reclamación económico administrativa acordándose que se dictara otra que tuviera en cuenta las alegaciones y prueba formuladas por el interesado en el trámite correspondiente.

SÉPTIMO: En fecha 5 de marzo de 2015, el Tribunal Económico Administrativo Central (en adelante TEAC) desestimó el recurso de alzada, desestimación contra la que se interpone en el presente recurso.

SEGUNDO.- El recurrente aduce los siguientes motivos de impugnación:

- Residencia Fiscal en Suiza.

Constan en el expediente administrativo certificados de residencia en los que consta que era residente fiscal en el año 2009 en Suiza, conforme al artículo 4 del Convenio de Doble imposición aplicable, que precisamente regula los criterios de la residencia fiscal, concepto que nada tiene que ver con el domicilio fiscal.

Además, el recurrente ha desvirtuado la presunción de residencia fiscal en España en caso de residir en este país su cónyuge y su hijo menor, que no se trasladaron con él a Suiza al padecer el niño una discapacidad cognitiva del 33%.

En cuanto a la fecha de la carta de despido, indica que fue suspendido de empleo con efectos del día 2 de diciembre de 2008, data en la que la empleadora le impidió el acceso al puesto de trabajo e inició una investigación para despedirle, dando lugar a un juicio laboral ante los Tribunales de Trabajo alemanes que duró 3 años.

-Exención de la indemnización percibida por el Sr. Inocencio .

El recurrente formaba parte del departamento de administración de la empresa y no ostentaba ni ejercía poderes que demostrasen la condición de personal de alta dirección regulada en el Real Decreto 1382/1985.

TERCERO.- Dado que en el origen de la resolución del TEAC de 5 de marzo de 2015 se encuentra una previa resolución de 28 de febrero de 2013, anulada por otra de 2 de junio de 2014, en virtud del correspondiente recurso de anulación, para que se tuvieran en cuenta las alegaciones formuladas por el interesado en el trámite correspondiente y que se omitieron como consecuencia del error -admitido- por dicho Tribunal, la resolución recurrida, analiza esos documentos en su Fundamento de Derecho Segundo, rechazando en el siguiente, el Tercero, la residencia fiscal del actor en Suiza, en los siguientes términos:

"TERCERO.- La supuesta residencia fiscal en Suiza desde el 01/04/2009 alegada por el reclamante.

1. Este Tribunal considera que, dentro del margen en que se desenvuelven, los razonamientos de la Oficina Gestora explican suficientemente la conclusión a la que llegan, ajustándose a Derecho y dando una respuesta satisfactoria acorde con los cánones de lógica y racionalidad exigibles a las actuaciones de la Administración pública.

2. Este Tribunal considera que la cuestión aquí planteada se refiere al tratamiento fiscal en España de una única renta: la abonada al interesado en 2009 por Hugo Boss Benelux BV y Cía S.C., una entidad española

titular del NIF A81556177 (a la que se refiere como Hugo Boss España) en concepto de sueldo y finiquito por un importe total de 485.344,22 ?.

3. Conforme a lo que resulta del Instrumento de ratificación del Convenio para evitar la Doble Imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio entre España y la Confederación Suiza ("Boletín Oficial del Estado" de 3 de marzo de 1967) (CDI Hispano Suizo):

«Artículo 15 Trabajo dependiente

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo, sólo pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Si el empleo se ejerce en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en este Estado.

2. No obstante las disposiciones del párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo ejercido en el otro Estado Contratante, sólo pueden someterse a imposición en el primer Estado si:

a) El empleado no permanece en el otro Estado, en uno o varios períodos, más de un total de 183 días durante el año fiscal considerado;

b) Las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona que no es residente del otro Estado, y

c) las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente o una base fija que la persona para quien se trabaja tiene en el otro Estado.»

Por consiguiente, la tributación en España de la renta de que se trata se produce tanto si el interesado es residente en este Estado como si no lo es. Y la aplicación de la ley española a esos efectos no está limitada - nada se dice al respecto en el CDI Hispano Suizo- ni porque la residencia pueda tener una diferente definición en la legislación suiza ni por la extensión de la tributación de esa renta.

4. El artículo 8.1 a) de la LIRPF dispone que son contribuyentes por el IRPF: "Ellas personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español." Y según su artículo 9:

"1. Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español. Para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el supuesto de países o territorios considerados como paraíso fiscal, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en éste durante 183 días en el año natural.

Para determinar el período de permanencia al que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las estancias temporales en España que sean consecuencia de las obligaciones contraídas en acuerdos de colaboración cultural o humanitaria, a título gratuito, con las Administraciones públicas españolas.

b) Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél. »

Por su parte, el art. 4, apartados 1 y 2, del CDI Hispano Suizo dispone:

«Artículo 4 DOMICILIO FISCAL

1. A los efectos del presente Convenio, se considera "residente de un Estado contratante" a toda persona que, en virtud de la legislación de este Estado, esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia (..) o cualquier otro criterio de naturaleza análoga.

2. Cuando, en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona física resulte residente de ambos Estados Contratantes, el caso se resolverá según las siguientes reglas:

a) Esta persona será considerada residente del Estado Contratante donde tenga una vivienda permanente a su disposición. Si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados Contratantes, se considerará residente del Estado Contratante con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales).

b) Si no pudiera determinarse el Estado Contratante en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados Contratantes, se considerará residente del Estado Contratante donde viva de manera habitual.

c) Si viviera de manera habitual en ambos Estados Contratantes, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado Contratante del que sea nacional.

d) Si fuera nacional de ambos Estados Contratantes, o no lo fuera de ninguno de ellos, las Autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso de común acuerdo.»

Sin embargo, como se habrá podido apreciar, los certificados aportados por emitidos por dos funcionarios del cantón suizo de Ticino no justifican la residencia fiscal del interesado en Suiza durante el ejercicio 2009. En ellos no se certifica que el interesado tenga su domicilio, residencia o cualquier otro criterio de naturaleza análoga en Suiza. Ambos se limitan a afirmar la sujeción del interesado con carácter ilimitado a los impuestos municipales, cantonales y federales en el cantón de Ticino. La documental consistente en la fecha y contenido de la carta de despido del reclamante, las nóminas y el llamado finiquito están en contradicción con esos certificados. Como mínimo en cuanto a la fecha de cese de la prestación de sus servicios a su anterior empleadora (Hugo Boss España, S.A.) que, como poco, se extiende hasta el 30 de Junio de 2009 contra la fecha de 01/04/2009 que se contiene en uno de los certificados. No se trata tan solo de ese dato tan relevante. La fecha de la carta de despido está fechada por la empleadora el 04/06/2009. No obstante lo cual al interesado se le satisface integra la nomina correspondiente al mes de junio de 2009 (obrante en el expediente). Por lo demás, el contenido de la carta de despido lleva al convencimiento de que hasta 30/06/2009, como poco, estaba en vigor la relación laboral entre el interesado y Hugo Boss España lo que desmonta la tesis de su supuesta residencia en Suiza desde el 01/04/2009.

Obra en el expediente la aportación por el interesado del modelo 030 (declaración del cambio de domicilio). En el formulario de presentación el interesado manifiesta "que se presenta el modelo 030 por traslado de mi residencia fiscal a partir de 2009 a Suiza", manifestando "que se tenga por presentado el modelo en cuestión." La fecha de presentación del 030 por el interesado en la Delegación Especial de la AEAT es 18/01/2010 como consta en el registro de entrada. Por parte de las personas físicas que, como es el caso, no formen parte del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, tiene un plazo de presentación de tres meses desde que se produzca el citado cambio. Lo que permite deducir, presumiendo el cumplimiento de la normativa española al respecto (presunción de actuación de buena fe del interesado), que el cambio se produce, al menos en lo que concierne a la Administración Tributaria de nuestro país, el 18/10/2009. Debe tenerse en cuenta que la comunicación del cambio de domicilio fiscal es una obligación de rango legal que se establece en el artículo 48 de la LGT-2003, cuyo apartado 3 dispone:

«3. Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda, en la forma y en los términos que se establezcan reglamentariamente. El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación, pero ello no impedirá que, conforme a lo establecido reglamentariamente, los procedimientos que se hayan iniciado de oficio antes de la comunicación de dicho cambio, puedan continuar tramitándose por el órgano correspondiente al domicilio inicial, siempre que las notificaciones derivadas de dichos procedimientos se realicen de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de esta ley.»

En el mismo sentido, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de Julio (con entrada en vigor el 01/01/2008). Conforme a su artículo 17 :

«Artículo 17. Obligación de comunicar el cambio de domicilio fiscal.

1. (...)

2. Tratándose de personas físicas que no deban figurar en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, la comunicación del cambio de domicilio se deberá efectuar en el plazo de tres meses desde que se produzca mediante el modelo de declaración que se apruebe, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

En el ámbito de competencias del Estado, la comunicación del cambio de domicilio deberá efectuarse de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior. No obstante, si con anterioridad al vencimiento de dicho plazo finalizase el de presentación de la autoliquidación o comunicación de datos correspondiente a la imposición personal que el obligado tributario tuviera que presentar después del cambio de domicilio, la comunicación deberá efectuarse en el correspondiente modelo de autoliquidación o comunicación de datos, salvo que se hubiese efectuado con anterioridad.

3. *La comunicación del nuevo domicilio fiscal surtirá plenos efectos desde su presentación respecto a la Administración tributaria a la que se le hubiese comunicado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 de este reglamento a efectos de la atribución de competencias entre órganos de la Administración tributaria.»*

Constituye circunstancia corroborante de la residencia fiscal en España del interesado en 2009, la de la empleadora Hugo Boss respecto a la Hacienda Pública española en la práctica de las retenciones por IRPF al interesado, incluido su tipo de gravamen y su inclusión en el modelo 190.

Además, el propio interesado no cuestiona que su esposa e hijo presentaron su declaración por el IRPF 2009 en España y este Tribunal considera que no se ha desvirtuado por prueba en contrario suficiente, la presunción establecida en el artículo 9 LIRPF a tenor de cuyo núm.1 *in fine*:

«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél.»

Por otra parte, la aplicación del criterio del *centro de intereses vitales* que prevé el artículo 9.1 b) de la LIRPF para entender que *tiene su residencia habitual en territorio español* es que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. Y no parece que haya dudas al respecto: su esposa y su hijo menor tenían y tienen residencia en España ya que es en este último Estado en donde han presentado su declaración por el IRPF y debe recordarse que conforme al art. 69 del CCiv español:

«Artículo 69.

Se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven juntos.»

También en España es donde, a falta de otra prueba que lo desvirtúe y que no se ha aportado por el interesado, esta ha obtenido la única retribución en 2009 (más de cuatrocientos mil euros que es una cantidad muy relevante)."

Frente a esos razonamientos el recurrente en su escrito rector, al que acompaña diversa documentación, indica que vivió, residió y permaneció desde el 1 de abril de 2009 en Suiza.

Procedemos a examinar su pretensión, en base a los documentos presentados ante la Administración, tal como ha realizado la resolución recurrida, valorando todos ellos, conforme a lo establecido en el artículo 218.2, de la LEC, es decir, conforme a una valoración conjunta de la prueba.

Pero antes de ésta valoración se imponen dos razonamientos que consideramos relevantes:

- a) Que la residencia fiscal en Suiza defendida por la parte, lo sería desde el 1 de abril de 2009.
- b) Que la indemnización recibida por el recurrente, origen del recurso que nos ocupa, lo fue por el trabajo desarrollado por aquel para la empresa Hugo Boss, desde el 1 de julio de 2002 hasta el mes de diciembre de 2008 (en concreto el 2 de diciembre).

Recuérdese que la devolución solicitada por el actor, se fundamentaba en la improcedencia de retener -incluida la cantidad de la indemnización por despido al 43 %-, cuando esa indemnización la parte la considera exenta conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley reguladora del IRPF, aplicable a los sujetos no residentes, en virtud de la remisión prevista en el artículo 24.1 de la Ley Reguladora del IRNR.

El artículo 9.1 de la LIRPF se dedica a regular los criterios que determinarán que una persona física tiene su residencia habitual en territorio español, entendiéndose que eso ocurre cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Vinculación física con el territorio: que permanezca más de 183 días, durante el año natural en territorio español (art. 9.1.a, LIRPF)
- Vinculación económica con el territorio: Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta (art. 9.1.b. LIRPF)
- Vinculación de la familia con el territorio: que resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél. Esta regla se configura como una presunción *iuris tantum* (art. 9.1.b, segundo párrafo LIRPF).

Entre los dos primeros criterios no existe prelación alguna en cuanto a su aplicación, no son criterios excluyentes, ni subsidiarios, aunque existen algunas diferencias en cuanto a la carga de la prueba. El tercero sí es de aplicación subsidiaria, siendo de aplicación en defecto de los dos anteriores.

La residencia fiscal de las personas físicas se determina para cada año o periodo impositivo.

La segunda circunstancia que determina la residencia habitual en territorio español es la radicación en España del núcleo principal o base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

El art. 9.1.b) LIRPF no define lo que debe entenderse por el núcleo principal o la base de las actividades o intereses económicos de un contribuyente; en cambio, a la hora de regular la residencia del contribuyente en la concreta Comunidad Autónoma, el art. 72 de la LIRPF sí establece los criterios para determinar dónde se encuentra el principal centro de intereses, definido por el lugar en que se obtenga la mayor parte de la base imponible del IRPF.

En lo que respecta a la vinculación al territorio español por motivos económicos, se ha considerado que el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, queda localizado en el lugar donde se ha obtenido el mayor volumen de rentas, es decir, si obtiene en España más rentas que en cualquier otro país (SAN de 29 de junio de 2006 o la Contestación de la DGT a Consulta vinculante nº 1539/04 de 4 de agosto de 2004).

También se ha identificado como el lugar donde se concentre la mayor de sus inversiones, donde radique la sede de sus negocios o desde donde administre sus bienes (STSJ de Cataluña de 29 de enero de 2004).

Adoptando una postura ecléctica se ha afirmado la necesidad de analizar, caso por caso, ambas cuestiones (renta obtenida e inversiones efectuadas), STS de 4 de julio de 2006 y SSTSJ de Galicia de 30 de abril de 2007 .

Se han considerado criterios objetivos que permiten radicar en centro de intereses económicos, en España o en cualquier otro país; gestión de explotaciones económicas, titularidad y utilización de inmuebles, urbanos o rústicos; titularidad y utilización de bienes muebles, principalmente vehículos; titularidad de otros derechos o cuentas bancarias, regularidad de movimientos bancarios, declaraciones en medios de comunicación, etc, resolución del TEAC de 9 de febrero de 2011, SAN de 20 de septiembre de 2001 , de 27 de junio de 2002 y de 17 de octubre de 2002 .

Enjuiciamos, por tanto si el recurrente puede ser o no considerado residente en Suiza desde el 1 de abril de 2009.

Hay que comenzar significando, como dice el actor, que debe diferenciarse claramente la residencia fiscal del domicilio fiscal, es decir, el lugar donde se localizan o centralizan las relaciones de la entidad con la Administración tributaria y que marca la competencia territorial de los distintos órganos de ésta.

El domicilio fiscal de los contribuyentes será el lugar en el que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios, que podrá coincidir o no con el domicilio social.

Con carácter subsidiario, cuando no pueda establecerse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores, prevalecerá aquél donde radique el mayor valor del inmovilizado.

1) Ya centrados en ese examen, debemos indicar, respecto de la permanencia en España por más de 183 días, que un elemento determinante es el certificado de residencia fiscal mediante el cual se acredite la residencia en otro territorio y que deberá expresar:

- Que la persona tiene su residencia fiscal en el Estado que lo expide. Las sentencias del TSJ de Asturias, de 28 de septiembre de 2007 y STSJ de Madrid, nº 10594/2008 , señalan que debe constar tanto su permanencia como sus obligaciones fiscales en el mismo.

- Que la persona está sujeta a imposición en dicho Estado por su renta mundial.

- Que se expide por la Autoridad fiscal competente.

- Si existe convenio para evitar la doble imposición (CDI), que la persona es residente en el sentido del Convenio.

En relación con el certificado de residencia emitido por la Administración Tributaria española habrá que estar a lo regulado en la disposición adicional 2ª de la Orden 3316/2010 de 17 de diciembre y a la que hace referencia también con acierto, el escrito rector, ha de significarse, como dice el Abogado del Estado, que dicha disposición adicional no es elemento relevante pues la norma se refiere al caso contrario al que nos ocupa, acreditar la residencia fiscal en territorio español ante autoridades extranjeras mediante la expedición del oportuno certificado.

En los certificados aportados por el recurrente, emitidos por las autoridades suizas del Cantón de Ticino de 16 de junio de 2009 y 17 de mayo de 2011, no se hace constar expresamente que el demandante tiene residencia fiscal en Suiza.

Ahora bien, también lo es que en el de 17 de marzo de 2011, si reseña a los efectos que hoy nos interesan, "Según el artículo 4 del Convenio entre la Confederación Suiza y España para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta", precepto que es el que regula el tema de la residencia fiscal hoy discutida.

Luego no es un elemento determinante pero si un indicio de cara a la conclusión a adoptar.

En cuanto a las discrepancias respecto de los distintos domicilios del recurrente pueden venir perfectamente explicados por el periodo a que afectan esos documentos, años 2009 y 2011.

2) En cuanto al contrato con la entidad Modeline (doc. nº2 de sus alegaciones ante el TEAC), asumimos todas las afirmaciones del TEAC, pues en él consta que se acuerda su incorporación a la empresa con fecha 1 de abril de 2009, que el domicilio del residente se sitúa en Madrid, sin que el contrato establezca la obligación por parte del actor de residir en Suiza.

Ahora bien, esa relación laboral viene acreditada a nuestro juicio, con las nóminas aportadas por el actor (doc. nº3 de la demanda) percibidas por el recurrente, derivadas del citado contrato y correspondientes al año 2009 (desde abril de ese año), la documentación bancaria -los extractos bancarios acreditativos de los gastos diarios que tenía el recurrente en Suiza (doc. nº2), -la comunicación de la empleadora Suiza, G.A. Modeline de 1 de julio de 2009, en la que se indica que ha superado el plazo de prueba de 3 meses (doc. nº4 de los acompañados al escrito rector), así como la comunicación de 20 de marzo de 2009 (doc. nº5) en la que se le indica los automóviles de la empresa que podría utilizar todos ellos con matrícula de Ticino.

Junto a esa documentación que la recurrente acompaña -en el escrito rector se habla de "improbo esfuerzo probatorio", -existen otros documentos, no puestos en cuestión por la representación del Estado, entre los que es preciso destacar, doc. 8, documentos del Órgano de Inmigración suizo, en los que consta como entrada en Suiza del recurrente el día 1 de abril de 2009, proveniente de España, haciéndose expresa referencia al contrato de trabajo con la entidad, G.A. Modeline y fecha de finalización de la actuación en dicho país el 31 de marzo de 2014.

Así mismo la documentación respecto del seguro médico con la compañía SW/CA Organización sanitaria vigente desde el 20 de abril de 2009 (doc. nº9), así como un certificado por hijos de la seguridad social de aquel país, con derecho a la correspondiente retribución (200 euros) desde el 1/04/2009 al 31/08/2009 (doc. nº 10) y un certificado emitido por las autoridades fiscales del Cantón de Ticino (doc. nº 12) de 23 de enero 2010 relativo al grado de ocupación del recurrente del 100%.

3) Nos queda por examinar, pues ya existen suficientes indicios de que el recurrente vivió y permaneció en Suiza desde el 1 de abril de 2009, la situación con relación a la entidad Hugo Boss.

La Administración sostiene que los servicios a esa entidad se extienden hasta el 30 de junio de 2009, pues la carta de despido está fechada el 4 de junio de 2009, habiendo recibido como mínimo la nómina del mes de junio. Además, respecto de este tema, se añade, en base a la fecha de presentación del modelo 030, que el cambio de domicilio a Suiza se produce el 18 de octubre de 2009.

Todos esos extremos están acreditados -con la salvedad que expondremos- a través de los documentos presentados por la recurrente en escrito ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en fecha 4 de enero de 2010 y en el que se pedía la devolución de 158.532,56 euros, si bien indica en su demanda, remitiéndose al doc. nº 9, de los aportados ante dicha Administración, que fue suspendido de empleo y sueldo el 2 de diciembre de 2008.

Y la salvedad indicada, es que la última nómina aportada por el actor es la relativa, aunque no resulta del todo legible, al mes de abril de 2009 y no al mes de junio como indica la Administración.

Y claro, este último dato es relevante, porque ayuda a cuadrar todos los elementos probatorios puestos en cuestión, que en caso contrario conducirían a un imposible, que durante el año 2009, y al menos hasta el mes de abril de 2009, el recurrente habría trabajado simultáneamente en dos países distintos y con empleos distintos también.

A saber: que el recurrente trabajó hasta abril de 2009, en la empresa Hugo Boss Ibérica, S.A. (Mad), recibiendo su finiquito en junio de 2009, derivada esta cuestión, que no ha quedado aclarada, de un presunto despido disciplinario a finales del año 2008.

Como consecuencia de esta situación el actor se traslada a residir y trabajar en Suiza, país en el que desde el 1 de abril de 2009, tenía residencia fiscal y trabajo.

La presentación del Modelo 030 es congruente con lo acontecido.

El que su mujer y su hijo continuaran residiendo en España, a efectos de la presunción contenida en el artículo 9, 1º.b), párrafo segundo del IRPF, que en este caso ha quedado completamente desvirtuada, tiene todo su sentido, pues su hijo es discapacitado, con una limitación del 33 %, tal como acredita la resolución de la Comunidad de Madrid, Consejería de Asuntos Sociales, de 10 de septiembre de 2012 (doc. nº 1 de los acompañados a la demanda) .

Y en España, a pesar de ese extremo, no puede considerarse que a partir del 1 de abril de 2009 naturalmente, tuviera su centro de intereses económicos, sino en Suiza, pues disponía de un inmueble en Mendrisio en el que vivía, tenía vehículos y era titular de cuentas bancarias, en las que se producían movimientos bancarios.

Por tanto, en el año 2009, el recurrente tenía residencia fiscal en Suiza, aunque en dicho año recibiera su indemnización por despido de Hugo Boss.

CUARTO.- El paso siguiente es determinar si era un empleado de alta dirección en la empresa Hugo Boss.

En el doc. nº 3 de los aportados al TEAC, comunicación de despido se indica que era "Director General (Gescharts Führer", de su "Condición de Alto Directivo", "Director General de Hugo Boss España, S.A." y de "relación laboral de Alto Directivo", cuestión simplemente negada por la parte aduciendo que todo el relato de la citada empresa no es lógico con el hecho de que posteriormente le indemnizaran con 300.000 euros.

Pero la parte, como a ella le incumbía, con arreglo al artículo 150.1 de la LGT de 2003, no ha aportado prueba alguna de su alegación, para rebatir los términos contenidos en dicha carta, en la que se le exige la entrega de tarjetas de crédito, llaves de las dependencias de la empresa, passwords y escrituras de poder, elemento éste último, propio de una actuación directiva y ejecutiva, propia del ejercicio de la gestión, la dirección y la representación de la compañía, incardinándose "plenamente en el desempeño del cargo de consejero de los órganos de administración de las empresas que revisten la forma jurídica de sociedad", como señala la STS, Sala IV, de 28 de diciembre de 1994, RCU 2889/1993, FJ3.

Y si ya ese extremo es relevante, en orden a considerar que el actor tenía la condición de Alto Directivo, existe otro elemento que corrobora esa conclusión, pues trabajó en Hugo Boss desde el 1 de julio de 2008 hasta el 1 de abril de 2009, recibiendo -de acuerdo con lo expuesto- un importe de 300.000 euros por su despido.

El recurrente se remite, asimismo, a sus nóminas hasta el 31 de diciembre de 2008, mes en que se le notificó que no volviera por la empresa, y el importe mínimo que recibe en las mismas -nos referimos a los meses de octubre y noviembre de ese año fue de 8.407,01 euros, cantidad que, en absoluto corresponde a un trabajador del departamento de administración de una empresa, aunque ese concepto figura en dichas nóminas, "Sección 015 administración" y en la de octubre de 2008 "Magnament" fuera del ámbito propio de la Administración de la empresa.

Si ello es así y existe aquella relación -la regulada en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto- toda la indemnización satisfecha al recurrente está sujeta al IRPF y a su sistema de retenciones a cuenta, SSTs de 3 de febrero de 2004 y 14 de diciembre de 2016, no procediendo exención alguna, DGT de 28 de noviembre de 2000.

De acuerdo con lo expuesto y como ha quedado acreditada la residencia fiscal en Suiza desde el 1 de abril de 2009, procede estimar la pretensión subsidiaria, relativa a la aplicación del 24% previsto para los contribuyentes no residentes.

Por todo lo expuesto procede estimar este motivo y, por ende, parcialmente el recurso.

QUINTO.- Con arreglo al artículo 139.1.2 de la LJCA cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

FALLO

En atención a lo expuesto y en nombre de Su Majestad El Rey, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de don Inocencio contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 5 de marzo de 2015, a que las presentes actuaciones se contraen, la cual anulamos por no ser conforme a derecho, ordenando la devolución al recurrente de 86.532,56 euros, más los correspondientes intereses de demora, resultante de la aplicación a las rentas obtenidas por el Sr. Inocencio en 2009 del tipo fijo del 24% previsto para los contribuyentes no residentes, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.



PUBLICACIÓN

Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente en la misma, Ilmo. Sr. D. JESÚS MARÍA CALDERÓN GONZALEZ estando celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; certifico.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ